

1500042-02.2022.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON APARECIDO LUCIANO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de EDSON APARECIDO LUCIANO, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 30 de janeiro de 2022, por volta de 01h20min, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1500042-02.2022.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500042-02.2022.8.26.0552

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON APARECIDO LUCIANO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de EDSON APARECIDO LUCIANO, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 30 de janeiro de 2022, por volta de 01h20min, na rua Batista Arnoni, Vila Maria, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, trazia consigo, em um notório ponto de venda de drogas, 21 porções de "cocaína" com peso bruto de 25,0 gramas, 19 porções de "maconha" com peso bruto de 24,0 gramas e 21 porções de "crack" com peso bruto de 7,0 gramas.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "guardas municipais passavam pelo local dos fatos, um notório ponto de venda de drogas nesta comarca, quando ali avistaram o denunciado em movimentação típica de traficância, pois postado em pé na rua em contato com o condutor de uma motocicleta de placas não

identificadas que ali parou, tendo este se evadido tão logo percebeu a aproximação da viatura, tomando rumo ignorado. Contudo, o denunciado foi abordado e com ele foi apreendida a pochete que trazia consigo, objeto comumente utilizado pelos vendedores nas biqueiras, a qual continha as drogas acima mencionadas, todas fracionadas e prontas para serem comercializadas, além da quantia de R\$ 175,00 em dinheiro, produto da venda ilícita. As circunstâncias e local da prisão, com a visualização de movimentação típica de traficância, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como a apreensão de quantia em dinheiro de origem não justificada demonstram, com segurança, que o denunciado trazia consigo e tinha em depósito os entorpecentes com a finalidade de tráfico."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

Transcorrida a instrução não há elementos que permitam inferir o elemento subjetivo específico do tipo.

De notar que a versão dos guardas municipais de que teriam avistado a suposta venda de drogas sequer consta do inquérito policial ou da denúncia. Da denúncia (fls. 108/110) consta apenas que houve um contato entre a pessoa imputada e o motociclista; do depoimento dos guardas perante a autoridade policial (fls. 02/03) consta apenas que estava em "atitude suspeita".

O acréscimo feito pelos guardas municipais em juízo de que teriam avistado uma venda é pouco crível, pois, da distância em que estavam, sequer conseguiram anotar o número da placa do motociclista.

Quanto a estar em ponto de tráfico com objetos embalados nos moldes em que são vendidos os entorpecentes é circunstância absolutamente inconclusiva, pois o ponto no qual se vende é o mesmo no qual se compra; a embalagem pela qual se vende é a mesma pela qual se compra. E as quantias encontradas não são incompatíveis com um uso semanal ou quinzenal das drogas.

Não há nada que indique que a pessoa imputada não estava ali só de passagem ou que apenas parou para conversar com a pessoa da motocicleta (ou como ela mesmo disse, para lhe dar um cigarro). Não houve sequer uma simples observação de que a pessoa imputada permaneceu no local por um mínimo de tempo que seja, a indicar que estava ali tão somente para vender as drogas.

Todavia, nem mesmo a condenação pelo art. 28 pode prosperar, eis que as provas foram obtidas em desconformidade com a lei e a Constituição.

Dando o devido respeito ao texto constitucional, as guardas municipais tem por função a proteção de bens, serviços e instalações dos municípios (§8º do art. 144). Seus agentes tem, enquanto "qualquer do povo", a faculdade de dar voz de prisão quando encontrarem alguém em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal).

Mas não possuem qualquer atribuição para proceder a diligências invasivas que levem ao desvendamento de infração que esteja fora do âmbito de atribuição de sua corporação..

O art. 37 da Constituição impõe a toda a administração o respeito ao princípio da legalidade, segundo o qual a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Aliás, para as guardas municipais esta exigência está expressa na parte final do §8º do art. 144.

Eis o que dispõe a lei complementar local de n.º 179, de 28 de novembro de 2017, com redação praticamente idêntica ao texto da Lei (federal) 13.022/2014 (grifos nossos):

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art. 3º São princípios, básicos, da Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira

aqueles elencados na Lei Federal nº 13.022/14.

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;

III - patrulhamento preventivo;

IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e

V - uso progressivo da força.

VI - compromisso com os princípios que regem a administração pública e respeito ao Estado Democrático de Direito.

Art. 4º É competência geral da Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira a proteção dos bens, serviços, logradouros públicos e instalações municipais e proteção às pessoas em todo Município, nos termos do § 8º, do art. 144, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Art. 5º São competências, específicas, da Guarda Civil Municipal; respeitadas as competências dos órgãos Federais e Estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

VI - exercer nas vias e logradouros municipais a fiscalização de trânsito, lavrar autuações e aplicar medidas administrativas, pelas infrações de circulação, parada e estacionamento, nos termos do art. 24 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança da comunidade;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, por meio da celebração de convênios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme Plano Diretor Municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários;

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno

e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Civil Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de Segurança Pública da União e do Estado, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV, deste artigo; diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Civil Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

Art. 6º É considerado serviço próprio do Guarda Civil Municipal, para todos os efeitos legais, inclusive a arregimentação, o exercício em cargo ou funções de natureza de segurança, bem como os de ensino e aprendizagem nos assuntos da área de sua atuação.

Art. 7º A Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira será custeada com recursos próprios consignados na Lei Orçamentária Anual, além de subvenções, donativos e contribuições.

Ora, partindo do princípio da legalidade, o máximo que podem os guardas municipais locais é "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário". Não há qualquer autorização para diante de suspeitas de flagrantes de delitos que estejam fora do domínio material de vigência das atribuições das GCMS proceder a medidas invasivas.

É preciso aqui fazer um alerta contra o argumento fácil e tentador de "quem pode o mais (prender), pode o menos (busca pessoal)". Como a decisão com base em valores abstratos exige a ponderação das consequências práticas (art. 20 do Decreto-Lei 4.657/42), é inevitável reconhecer que a prisão é o ato de polícia máximo, razão pela qual este raciocínio é inválido por legitimar uma verdadeira equiparação das guardas municipais às polícias, conferindo a elas um poder de polícia completo. Mais. Não se pode desconsiderar a interpretação sistemática do feixe de atribuições instituído pelo constituinte no art. 144, o qual confere às polícias militares a função da patrulhamento ostensivo. De forma que as diligências preventivas, com as exceções expressas da constituição para a polícia federal (tráfico, contrabando e descaminho, policiamento marítimo, portuário e de fronteiras) e as guardas municipais (bens, serviços e instalações municipais), cabem tão somente às PMs. Vale ressaltar que é exatamente nesse sentido o entendimento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei municipal 13.866/06 que fixava, dentre as atribuições da guarda municipal da capital, "exercer, no âmbito do Município de São Paulo, o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos", assim entendeu o órgão máximo do tribunal. Confira-se a ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade - art. 1º, inc. I da Lei n. 13.866/2004, do Município de São Paulo, que fixa atribuições da Guarda Civil Metropolitana - Art. 147 da Constituição Estadual - Proteção dos bens, serviços e instalações municipais - Matéria debatida é atinente à segurança pública - Preservação da ordem pública - Competência das polícias, no âmbito do Estado - Atividade que não pode ser exercida pelas guardas municipais - Extrapolação dos limites constitucionais - Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo. (ADI nº 154.743-0/0-00, Rel. Des. Mauricio Ferreira Leite, j. 10/12/2008).

Trata-se, como se percebe, de entendimento consolidado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei 5.626, de 16 de abril de 2018, do Município de Valinhos, que assegurou à Guarda Municipal a identificação como 'Polícia Municipal de Valinhos' - Alegação do Prefeito, autor da ação, de usurpação da competência privativa do Poder Executivo para disciplinar matéria sobre a organização dos serviços públicos municipais, violando a separação os poderes -

VÍCIO DE INICIATIVA – Projeto apresentado por parlamentar direcionado à nova designação da Guarda Municipal – Matéria claramente de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme interpretação dos artigos 5º, 24, § 2º, item 4, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, alínea 'a', da Constituição Bandeirante, aplicável aos Municípios por força do seu artigo 144 – Incidência, ainda, do preceito do artigo 147 da Carta Bandeirante, que reproduz o texto do artigo 144, § 8º, da CF/88, que estabelece que a guarda municipal é força de natureza civil destinada à proteção de bens, serviços e patrimônio municipal, sem se imiscuir na Segurança Pública preventiva e ostensiva de atribuição dos Estados e União – Inconstitucionalidade das guardas municipais adotarem a identificação de 'polícia', e ainda mais como 'militar', dada sua natureza civil – Não violação, por outro lado, dos preceitos orçamentários, segundo Tema 917, em repercussão Geral, no S.T.F. – Ação julgada procedente. TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2286983-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo – N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020.

É essa também a lição da doutrina constitucionalista.

José Afonso da Silva (Comentário Contextual à Constituição, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638/639) assevera que:

Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de Polícia Municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com qualquer responsabilidade específica pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que, sendo entidades estatais, não podem eximir-se de ajudar os Estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança, e menos ainda de polícia judiciária. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí, certamente, está uma área que é de segurança: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal, que envolve bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é de polícia ostensiva, que é função da Polícia Militar. Por certo que não lhe cabe qualquer atividade de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, que a Constituição atribui com exclusividade à Polícia Civil (art. 144, §4º), sem possibilidade de delegação às Guardas Municipais.

Pinto Ferreira (Comentários à Constituição Brasileira, v. 5, p. 246) observa que:

A Constituição de 1988 atribuiu às Guardas Municipais a tarefa de proteção aos bens, serviços e instalações do Município, conforme dispuser a lei (art. 144, § 8º), não as fazendo auxiliares da Polícia Militar nem lhes conferindo função repressiva dos crimes.

Lesley Gasparini Leite e Diógenes Gasparini (Lesley Gasparini Leite e Diógenes Gasparini, Guarda Municipal - Criação e Implantação - Constituição Federal - Constituição Estadual - Lei Orgânica do Município, in Boletim de Direito Municipal, ano IV, nº 3, pág. 203) também destacam que às guardas municipais “não lhes cabem, portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de Polícia Judiciária e de apuração das infrações penais. Aliás, essas competências foram essencialmente atribuídas à Polícia Militar e à Polícia Civil”. Não diverge a melhor doutrina processual penal. Gustavo Badaró (Processo Penal, 3ªed, 2015, p. 496), professor titular de Direito Processual Penal da USP, afirma que:

(...) há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes.

O Desembargador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal comentado, 2017), por sua vez, ensina:

Agentes autorizados a realizar busca pessoal: são os que possuem a função constitucional de garantir a segurança pública, preservando a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como investigar ou impedir a prática de crimes: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares (art. 144, CF). Não possuem tal função os agentes das guardas municipais, logo, não estão autorizados a fazer busca pessoal. Naturalmente, se um flagrante ocorrer, podem prender e apreender pessoa e coisa objeto de crime, como seria permitido a qualquer do povo que o fizesse, apresentando o infrator à autoridade policial competente.

Enfim, qualquer que seja o caminho argumentativo, não podem os membros das guardas municipais proceder à qualquer diligência invasiva para apurar delito que não tenha qualquer correlação com a proteção bens, serviços ou instalações municipais. Ora, se mesmo quando diante de flagrante delito, cabe a eles somente encaminhar o autor da infração ao delegado de polícia, por qual razão poderiam proceder à busca pessoal se sequer sabiam se a pessoa acusada encontrava-se nessa situação? Se tinham fundadas suspeitas de cometimento de crime grave (equiparado a hediondo) por parte da pessoa imputada, deveriam ter, em respeito ao texto constitucional, comunicado à Polícia Militar e/ou Civil para que tomassem as medidas necessárias.

A disciplina constitucional (art. 5º, inciso LVI) é inequívoca:

são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos

Como a diligência foi ilícita, ela não pode ser admitida como prova da infração penal.

Como a prova da imputação não possui outra fonte independente (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal), é forçoso reconhecer não há prova da materialidade do delito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER EDSON APARECIDO LUCIANO das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Em razão da absolvição, determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do réu, vez que foram infirmados em cognição plena os indícios de autoria, necessários à custódia cautelar.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Expeça-se certidão de honorários.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 5 de maio de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA